

1500116-36.2022.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500116-36.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-36.2022.8.26.0591

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

José Miguel Lopes Alves Marcato

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOSÉ MIGUEL LOPES ALVES MARCATO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de maio de 2022, às 14h56min, na Estrada 1, Vicinal do Bairro Oásis, nesta cidade e comarca de Dracena/SP, o denunciado trazia consigo droga (cocaína), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na mesma data, momentos depois, no imóvel localizado na Rua Antônio Rodrigues de Barros, nº 1345, bairro Santa Clara, nesta cidade e comarca de Dracena/SP, sua residência, o denunciado mantinha em depósito e guardava drogas (cocaína e maconha), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva em 15/05/2022 (fls. 78/81).

Foi deferido o pedido de quebra de sigilo telefônico (fls. 109/110).

Regularmente notificado (fls. 234), o réu apresentou defesa prévia (fls. 155/166).

Recebida a denúncia em 22/06/2022, foi designada audiência de instrução, debates e

juízo virtual, a ser realizada por meio de videoconferência (fls. 181/184). Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu (cf. mídia). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e a revogação da prisão preventiva do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 17/18), pelas fotografias da substância entorpecente (fls. 19/22), pelos laudos periciais de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 29/34; 35/40; 41/46 e 47/52), pelo laudo pericial do local do fato (fls. 94/100), pelos laudos periciais de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 118/120; 123/125; 126/128 e 129/131), pelo laudo pericial da balança de precisão (fls. 136/139), pelo laudo pericial de degravação de celular (fls. 198/227), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha comum Vagner César Alves, policial militar, disse que em patrulhamento na vicinal Oásis que liga Dracena a Tupi Paulista, é local conhecido como rota de tráfico de drogas. Visualizou uma motocicleta conduzida com uma moça com um rapaz na garupa. Viu o réu conversando com a moça, ocasião em que ela acelerou. Dado sinal, a moça acelerou e não parou. Na abordagem, havia drogas no bolso do réu, sendo uma porção de "Crack" e outra porção de "Maconha". Em revista pessoal, o réu disse que tinha drogas e estava levando para Tupi Paulista e ganharia R\$ 1.000,00 pela venda. No outro bolso foi localizado o valor de R\$ 385,00 e um celular. Em diligência na casa do réu, encontrou a esposa dele, Sra. Daiana Mara, autorizou a entrada dos policiais para averiguar. No armário da cozinha foram localizadas mais uma porção de "Crack" e mais duas porções de "maconha" e mais uma balança de precisão. Já era de conhecimento dos policiais que o réu era envolvido com o tráfico de drogas e não com o uso (cf. mídia).

A testemunha comum Fernando Ono Maki, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela vicinal Dracena quando avistou a motocicleta conduzida por Aline. Em alguns metros a frente, foi realizada a abordagem. Com o passageiro foi localizada droga e ele disse que levaria até Tupi Paulista e receberia o valor de um mil reais pela venda. Com o réu foi apreendido celular e R\$ 381,00 em dinheiro. O réu não disse nada sobre o dinheiro. O réu disse que tinha mais droga em sua residência, onde foi localizada mais porção de "Crack" e maconha, além de balança de precisão. Esclareceu que o réu estava lúcido. O réu de imediato disse que a droga era sua, que vendia droga e levaria para Tupi Paulista (cf. mídia).

A testemunha comum Aline Cristina da Silva disse que o réu ligou para a depoente pedindo uma corrida até a casa da mãe dele. A depoente não estava mais fazendo corrida. O réu pediu para deixá-lo na casa da mãe dele porque ele precisava receber um dinheiro em Tupi Paulista. A mãe dele não estava e o réu disse que precisava ir até Tupi Paulista. O réu perguntou o valor e a depoente disse que era oitenta reais. O réu disse que seria rápido porque só iria buscar o dinheiro. Não viu os policiais localizando a droga com o réu. Quando a Polícia disse que encontrou a droga com o réu ele não negou nada. Depois foram tudo para a Delegacia. Conhece o réu e sabe que ele é usuário de drogas. Ele tem uma filha. Não desconfiou de nada porque ele trabalha (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu JOSÉ MIGUEL LOPES ALVES MARCATO disse que a droga era sua. Pegou a droga porque trabalhava registrado mas não conseguia pagar suas contas. Pretendia vender a droga por um mil reais. Faz um mês ou dois meses que vendia drogas. Só pegou drogas para pagar suas contas. Vende gás e tem rendimento mensal de R\$ 1.500,00. Tem uma filha pequena para quem paga pensão alimentícia. Morava com sua ex-namorada. Não foi preso antes e nem respondeu a outro processo criminal. Pagou R\$ 500,00 na droga (cf. mídia).

Pois bem, o réu é confesso e sua confissão judicial se mostra em consonância com o conjunto probatório produzido.

Segundo o apurado, os agentes policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu na garupa da motocicleta conduzida pela testemunha Aline Cristina da Silva que, na ocasião, desempenhava a função de mototaxista. Durante a abordagem pessoal, constatou-se que o réu trazia consigo, dentro do bolso de sua bermuda, 01 (uma) porção de "crack" e 01 (uma) de cocaína. Na sequência, em diligências na residência do réu, foi encontrada substância entorpecente no armário da cozinha, consistente em 01 (um) invólucro de "crack" e diversas porções de "maconha". No local também foi apreendida uma balança de precisão, um aparelho celular e a importância de R\$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) em espécie.

Portanto, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida: (a) a natureza, a expressiva quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendida, a saber: 01 (um) invólucro, com massa líquida de 27,75g (vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas), da substância cocaína (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 29/37 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 126/128); 01 porção, com massa líquida de 70,16g (setenta gramas e dezesseis centigramas) da substância "tetra-hidrocanabinol" ("maconha") (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 35/40 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 129/131); 01 porção, com massa líquida de 24,2g (vinte e quatro gramas e vinte centigramas) da substância hidrocanabinol" ("maconha") (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 41/46 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 123/125), 01 invólucro, com massa líquida de 7,42g (sete gramas e quarenta e duas centigramas) (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 47/52 e laudos periciais de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 118/120); (b) a quantia de R\$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) em espécie apreendida em poder do réu (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18; (c) o laudo pericial da balança de precisão localizada na residência do réu de fls. 136/139; (d) o laudo pericial de fls. 198/227 realizado no aparelho celular apreendido na posse do réu contendo conversas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como imagens de substância entorpecente encontradas no armazenamento interno do aplicativo "WhatsApp"; (e) a própria confissão judicial do réu que, em Juízo, disse que pretendia fazer um dinheiro com a droga, revendendo o entorpecente por R\$ 1.000,00 (um mil reais). Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziram em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu.

Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo os laudos de substâncias entorpecentes (fls. 118/120, 123/125, 126/128 e 129/131), comprovarem a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação

mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Ademais, a prova oral foi corroborada pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 118/120, 123/125, 126/128 e 129/131), atestando positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e COCAÍNA, bem como pela quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado (cf. auto de exibição/apreensão fls. 17/18) e pelo laudo de degravação de celular de fls. 198/227 contendo conversas relacionadas à comercialização de substância entorpecente.

Ainda, o laudo pericial de fls. 136/139 examinou a balança de precisão apreendida na residência do adolescente, constatando que: "O receptáculo destinado à bateria encontrava-se tampado, com duas baterias de marca aparente PENESAMIG. A capacidade máxima da balança era de 10 Kg e mínima (ou sensibilidade) de 1g. Por ocasião da perícia encontrava-se funcionando normalmente. O artefato é apto à pesagem de entorpecentes". (ITEM III - DA PEÇA E DOS EXAMES - fls. 138).

O laudo pericial do local de encontro de entorpecentes acostado a fls. 94/100 demonstrou por meio de fotografias o local onde os entorpecentes foram encontrados - "No armário localizado ao lado da geladeira" (fls. 97/98) - e a forma que estavam acondicionados, bem como a balança de precisão apreendida em conjunto com as substâncias.

Outrossim, o laudo de degravação de celular acostado a fls. 198/227 constatou as trocas de mensagens gravadas no aplicativo "WhatsApp" do réu José Miguel com o indivíduo de nome Bruno, nº +55 18 99625-3254 (cf. lista de contatos fls. 205), no dia 14 de maio de 2022 (fls. 206):

Bruno: "[...] Tem uma maconha pra me solta hj não?"

José Miguel: "[...] não tenho mais maconha, não. Só um pedacinho ali ainda que eu tô vendendo pro mano ali, umas 70 g que ele vai pregá agora. Acabou tudo.

Ainda, é possível verificar outras conversas do réu relacionadas à comercialização de droga nas mensagens de áudio gravadas a fls. 213/214: "vende este restinho deste óleo aí e a hora que vocês pegá o fogão não liga o forno do fogão, não... vai jogá meu dinheiro no lixo"; "[...] Dá um salve pra Miriele. Chama ela pra bolá um baseado pra vocês fumá"; "Deixa eu te fala, aquele óleo não acabou ainda, não? Aquele pedacinho aí que tava dentro. Tem mais lá dentro do forno. Cuidado liga o forno aí!x; "[...] tem dois pedacinho: um grande e um pequeno, preto, pega o preto que o preto tem 10. O outro tem que pesá ainda." "Tem que pará de fumá um pouco... essa porra desse cigarro e essa maconha aí também".

Em outra conversa entre o réu e a pessoa identificada como "Mor" (fls. 214):

Mor: "[...] veio uma parceira aqui, mil grau, Lá dentro ela vendia um chá. Eu comprava dela. É um sapatão... veio aqui compra um chá hoje. Na rodoviária pediu praquele nória que tava me devendo trezentão e ele deu meu nome, Miguel, dizendo que tava acendendo droga minha... me chamou no face e eu passei o zap...".

José Miguel: "[...] porque vc comprava lá dentro vai fica dando um monte pra esses aí... fica aí cheio dessa de enche a mão dos outros...".

Mor: "ah! Se liga! Só dei dezão. Não sô assim não. "Não, Mor. Tô fazendo o dinheiro aqui. Quando chega vc faz igual vc sempre faz: recolhe e assuma. Vc só pega e taca ali dentro".

José Miguel: "Vc vai vê. Tem uns R\$ 900 e tem uns dinheiro do lado. Não sei onde vc pôs... deixa esses 150. Dá só os 400 pra ele. Tem os 400 pra ele aí picado. Tem uns picado no meio... bom que mora, falta só R\$1.000, fala pra ele [...] eu tenho que leva uma firta. O mano tá querendo 100 g. Vamo vê se ele vai quere mesmo. Cem mais um óleo".

Ademais, no laudo de degravação foi possível verificar transferências bancárias via "Pix", nas quais o réu recebe uma diversidade de valores de R\$ 10,00 (dez reais), R\$ 20,00 (vinte reais), R\$ 80,00 (oitenta reais), R\$ 100,00 (cem reais) (fls. 218). Inclusive, o "Pix" do valor de R\$ 100,00 (cem reais) foi recebido de Miriele

Cecilio da Silva, pessoa que o réu pede para o contato "Mor" dar um "salve" e chamar ela para "bolá" um baseado para elas fumarem (cf. Conversa transcrita acima de fls. 213), o que leva a crer que as transferências bancárias recebidas são provenientes do tráfico de drogas.

Outrossim, é possível verificar imagens do réu segurando cigarros de "maconha" no armazenamento interno compartilhado do aplicativo "WhatsApp" de seu celular (fls. 221/223).

Portanto, a autoria é indubitosa e a materialidade está estampada nos autos.

Com efeito, a julgar pela expressiva quantidade, natureza, variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, a saber: 01 porção de "maconha" pesando 70,16g (setenta gramas e dezesseis centigramas), além de outras porções de "maconha" pesando 24,2g (vinte e quatro gramas e vinte centigramas); 01 invólucro de "cocaína" com peso líquido 27,75g (vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas) e 01 invólucro da mesma substância entorpecente pesando 7,42g (sete gramas e quarenta e duas centigramas), bem como a quantia de R\$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) em espécie apreendida em poder do réu, aliada às conversas encontradas em seu telefone celular relacionadas à comercialização de drogas, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, mesmo que o réu não tenha sido flagrado comercializando a substância entorpecente, o simples fato de trazer consigo é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agentes." (RT 584/347).

Outrossim, a circunstância de ser o réu usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre a mesma pessoa.

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente precisa ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para

confeção de um "fininho de maconha" são necessários 0,33 da referida droga, o que indica que a "maconha" apreendida em poder do réu, com peso líquido de 94,36 gramas, era suficiente para confecção de mais de 280 (duzentas e oitenta) porções individuais! Ainda, para confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que a "cocaína" apreendida em poder do réu, cujo peso líquido totalizava 35,17 gramas, era suficiente para a confecção de mais de 3.500 (três mil e quinhentas) porções individuais!

Tal assertiva deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu.

Assim, na espécie, o réu infringiu a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, trazer consigo, manter em depósito e guardar substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a natureza, a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para uso pessoal, tudo indicando claramente o tráfico, motivo pelo qual fica afastada a pretensão de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Deve-se, também, reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão da versão apresentada pelos policiais em Juízo é firme o suficiente para concluir que o dinheiro apreendido em poder do réu era oriundo do tráfico de drogas e o aparelho celular e a balança de precisão eram utilizados para a traficância, razão pela qual devem ser declarados perdidos.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário (cf. folha de antecedentes - fls. 66 e certidão - fls. 67). Contudo, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, considerando a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida (94,36 gramas de "maconha" e 35,17 gramas de "cocaína"), as quais evidenciam o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado, além de impor maior reprimenda, porque os efeitos deletérios da "maconha" e da "cocaína" ao usuário e ao meio familiar e social em que se insere são por todos conhecidos, trazendo maior grau de censurabilidade à conduta do réu, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A propósito, nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DEFLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papéletes de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS

2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)".

"(...) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)".

Na segunda fase de aplicação da pena, presente as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal (cf. qualificação do réu no Boletim de Ocorrência - D.N.: 29/10/2003 - fls. 15/16), porque o réu confessou espontaneamente os fatos e na data dos fatos o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade, motivo pelo qual reduziu a reprimenda a seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu trazia consigo e mantinha em depósito expressiva quantidade de substância entorpecente, a saber: 94,36g de "maconha" e 35,17g de "cocaína", tudo a indicar que o acusado é pessoa dedicada à atividade criminosa, a evidenciar que não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de drogas, conforme ficou demonstrado pela versão dos policiais ouvidos em Juízo e pelo laudo pericial de degravação das conversas do celular, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade, já que com o réu foi apreendida expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente, sendo indicador de seu envolvimento com o vil comércio. Convém ressaltar que se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias. Portanto, afasto a pretensão da defesa de aplicação do privilégio.

Assim, torno definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, tendo em vista a expressiva quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida em poder do réu, aliado ao fato de que foram encontradas conversas no celular do réu de envolvimento com a comercialização de drogas, bem como considerando que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sua aplicação não seria

possível diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida suficiente e adequada. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Assim, embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal cumulativos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou." (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Pelo montante da pena aplicada, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu JOSÉ MIGUEL LOPES ALVES MARCATO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 78/81), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendidas em poder do réu, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a custódia cautelar do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento da quantia de R\$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) em dinheiro, do aparelho celular, marca Motorola, cor azul e da balança de precisão apreendidos em poder do réu (cf. autos de exibição e apreensão a fls. 17/18) em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Se o caso, na forma do previsto no artigo 58, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa. Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de

beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Fixo os honorários do advogado nomeado nos termos da tabela do convênio OAB/DPE, se o caso. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão.

Custas na forma da lei.

Considerando que o réu foi patrocinado por advogado dativo, defiro a ele os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Não obstante o condenado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, o mesmo fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060 /50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Dracena, 07 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA